

1513030-39.2021.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... pelo afastamento da hediondez do delito de tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO E POR TRÁFICO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006.

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA AFASTADA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513030-39.2021.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513030-39.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2282387/2021 - 04º D.P. AMERICANA, 20855708 - 04º D.P. AMERICANA, 1504/21/350 - 04º

D.P. AMERICANA, 2282387 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 1504/21/350 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO APARECIDO DA ROCHA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

GUSTAVO APARECIDO DA ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006, porque, na data e local descritos na denúncia, trazia consigo e tinha em depósito, para o fim de consumo de terceiros, substância entorpecente (01 micro tubo contendo cocaína; e 25 micro tubos contendo cocaína, revelando peso líquido de 4,4g) que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A denúncia de fls. 94/95, foi recebida em 22 de fevereiro de 2022 (fls. 128/129). O réu foi citado pessoalmente (fls. 110), apresentando defesa prévia (fls. 122/123).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas arroladas. O réu deixou de comparecer ao interrogatório, tornando-se revel (fls. 179/180 e 182).

Foi homologada a desistência a testemunha restante, e encerrada a instrução (fls. 194).

Em seus memoriais (fls. 199/202), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

O Doutor Defensor do réu (fls. 205/232), requereu a absolvição por falta de provas, a desclassificação ou a aplicação da conversão em restritivas.

Ante a apresentação de matéria preliminar, os autos retornaram ao Ministério Público para manifestação (fls. 238/239).

É, em síntese, o relatório.
DECIDO.

A preliminar suscitada pela Douta Defesa deve ser afastada.

Com efeito, já é pacífico na jurisprudência a possibilidade do guarda municipal realizar a prisão, porque nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer do povo pode realizar prisão em flagrante. Além disso, o direito à inviolabilidade do domicílio, revisto no artigo 5º, XI da Constituição Federal, possui exceção no próprio artigo, ao ressaltar os casos de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Como se vê, são quatro exceções: uma delas, a determinação judicial, mas neste caso somente durante o dia; as outras três não possuem limitação temporal, podem ser durante o dia ou mesmo durante a noite, basta que estejam ocorrendo naquele momento. Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. ART. 301 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão. 3. (...). 4. Ordem denegada. (HC 129.932/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 01/02/2010)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. INOCORRÊNCIA. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. (...). 2. É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a

função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado no caso dos autos, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que possui outros registros criminais, já tendo sido, inclusive, condenada, o que demonstra a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 5. (...). 9. Habeas corpus não conhecido. (HC 549.805/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020)

A presente demanda originou-se de realização de diligência policial de rotina para a verificação de ocorrência e preservação, e não trabalho investigativo por parte dos policiais. A indicação de que o local conhecido pelo tráfico de drogas, e existência de terceira pessoa evadindo-se nas proximidades, além da ação do réu ao dispensar algo ao solo, somada a localização de substância entorpecente, comprovam a legalidade dos atos perpetrados.

Dessa forma, diversamente do sustentado, nenhum abuso, ou nulidade, ocorreu na diligência policial. Tratando-se "de crime permanente, a ensejar sempre prisão em flagrante, não há que se questionar sobre a preexistência, nulidade ou descumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, porque a inviolabilidade domiciliar é princípio que não se compadece, em termos infracionais, com o desvio de finalidade da função da própria casa, conforme se infere do disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal" (JCAT 75/590).

Por fim, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, "proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida; 'coisas achadas ou obtidas por meios criminosos' (art. 240, § 1º, b, do CPP); 'instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos' (art. 240, § 1º, c, do CPP); 'armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso' (art. 240, § 1º, d, do CPP); 'objetos necessários à prova de infração ou à defesa do autuado' (art. 240, § 1º, e, do CPP); 'cartas, abertas ou não, destinadas ao autuado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato' (art. 240, §1º, f, do CPP); e 'qualquer elemento de convicção' (art. 240, § 1º, h, do CPP)".

A alegação de nulidade por ausência de justa causa para a revista não deve prosperar no presente caso. Conforme delimitado nos autos do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), pelo Superior Tribunal de Justiça, a busca deve ser, "baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência", o que resta presente, posto que os policiais localizaram a substância entorpecente.

No mais, a fundada suspeita, considerando, também, que o local é conhecido pelo tráfico, e restou comprovada pela apreensão de drogas, as quais foram dispensadas pelo réu, quando visualizou a ação policial.

Desta forma, a conduta dos policiais restou fundada na justa causa, em especial pela necessidade de imediata cessação da conduta criminosa, não se tratando de

medida ilegal e abusiva.

Por fim, no processo penal não se cogita da imposição da pena de confissão ao réu, ante a ocorrência de sua revelia, tendo em vista o disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, sendo uma das consequências o andamento dos autos sem a necessidade de sua presença (art. 367, do CPP), além da possibilidade de decretação da prisão preventiva (art. 312, do CPP).

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes se encontra comprovada pelos laudos de fls. 82/84.

É notório o perigo à incolumidade pública causado pela droga conhecida como cocaína, de alto poder viciante e que causa dependência física e psíquica, demonstrando estar plenamente caracterizada a prática delitiva.

De acordo com a doutrina:

"É tão grave a nocividade dessa droga que, mesmo depois da cura pela desintoxicação, o viciado não se recupera das lesões mais graves do sistema nervoso. Tem estados depressivos e de angústia, alucinações visuais e tácteis, delírios de perseguição e complexo de culpa. Envelhece muito precocemente, e a morte é quase sempre por perturbações cardíacas" (DE FRANÇA, GENIVAL VELOSO. Medicina Legal. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004, p.308).

A esse respeito, a matéria publicada no conceituado jornal "Folha de São Paulo"; em 30 de dezembro de 1994:

"Cocaína é maior causa de infarto em jovens

A cocaína é responsável por quase todos os infartos do miocárdio em jovens com menos de 30 anos. A constatação é da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) que lança na próxima semana uma campanha nacional de informação.

O objetivo é esclarecer as pessoas sobre as doenças do coração e o que se deve fazer para evitá-las. Entre os jovens, o uso da cocaína é o que mais preocupa a SBC.

"Eles precisam saber que a cocaína tem efeitos mortais no organismo", diz Claudio Buarque Benchimol, 47, secretário-geral da SBC. "Quase todos os jovens que chegam com infarto nos hospitais fizeram uso de cocaína", afirma.

É o que acontece no Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas, umas das mais importantes portas de entrada de vítimas de infarto em São Paulo.

O cardiologista Marcello Barduco, do pronto-socorro do Incor, confirma que entre os jovens a causa do infarto está quase sempre associada ao uso de cocaína.

O hospital registra uma média de um a três casos de infartos em jovens por mês. A cada 24 horas, o Incor recebe uma média de cinco vítimas de infarto, idosos na grande maioria.

Não há estudos sobre os riscos nem estatísticas sobre casos de infarto por droga entre jovens. De acordo com Benchimol, o número de mortes do coração provocado por cocaína pode estar subnotificado por interferência da família. Ou mesmo pela dificuldade em se apontar a droga como causa.

De todo modo, o número de jovens que morrem por infarto é pequeno. Segundo dados da Fundação Seade, apenas 33 jovens entre 15 e 29 anos morreram de infarto do miocárdio na cidade de São Paulo no ano passado. Para se ter uma idéia, nesse mesmo período, 2.298 jovens dessa faixa de idade foram assassinados com armas de fogo e outras armas. Outros 561 morreram no trânsito.

A preocupação da SBC é com o aumento do uso da cocaína registrado nos últimos anos.

"O número de usuários dessa droga vem aumentando no mundo todo", diz Benchimol.

Pesquisa feita entre estudantes de 1º e 2º graus de dez capitais brasileiras mostra que 1,2% deles já experimentou cocaína. Cinco anos atrás, apenas 0,7% dos estudantes tinham usado a droga uma vez. A pesquisa foi feita pelo Cebrid, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas.

O perigo da cocaína é apenas um dos itens da campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Os médicos pretendem informar em linguagem simples como se iniciam as doenças do coração e o que pode agravá-las ou fazer com que regredam. A hipertensão arterial e o fumo, por exemplo, são fatores de risco para um infarto. Alimentação correta, pouco estresse e exercícios físicos ajudam a manter o coração mais saudável.”

E ainda:

“A quantidade necessária para provocar uma overdose varia de uma pessoa para outra, e a dose fatal vai de 0,2 a 1,5 grama de cocaína pura. A possibilidade de overdose, entretanto, é maior quando a droga é injetada diretamente na corrente sanguínea. O efeito da cocaína pode levar a um aumento de excitabilidade, ansiedade, elevação da pressão sanguínea, náusea e até mesmo alucinações.

(...)

A cocaína é a droga que mais rapidamente devasta o usuário. Bastam alguns meses ou mesmo semanas para que ela cause um emagrecimento profundo, insônia, sangramento do nariz e coriza persistente, lesão da mucosa nasal e tecidos nasais, podendo inclusive causar perfuração do septo (12). Doses elevadas consumidas regularmente também causam palidez, suor frio, desmaios, convulsões e parada respiratória”. (S.H. Cardoso e R.M.E. Sabbatini; Revista Cérebro & Mente 3(8), jan/mar 1999).

A autoria, relativo ao tráfico, é indubitosa.

O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho “é a certeza visual do crime”. A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

“Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria” (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Tanto na fase de investigação, quanto em Juízo, os guardas municipais informaram que se encontravam em patrulhamento pela rua e verificaram uma pessoa parada em frente a uma residência, sendo que ao avistar a viatura, esta pessoa saiu caminhando. Ao chegarem em frente ao referido imóvel, conhecido como abandonado e frequentado por traficantes e usuários de drogas, avistaram o réu no corredor do imóvel, escalando o muro e acessando a calha da casa vizinha. Narraram que o réu,

ao perceber a abordagem, desceu do muro e dispensou um objeto ao solo. Em revista pessoal, com o réu localizaram uma quantia em dinheiro, de três reais, e, no objeto dispensado, uma porção de substância entorpecente, aparentando ser cocaína. Disseram, ainda, que ao verificar o local na calha, onde o réu estava mexendo, localizaram mais vinte e cinco porções de cocaína, semelhantes a encontrada com o réu. Declararam, também, que a testemunha Fagner, nome social Fernanda, informou que presenciou quando um terceiro pediu ao réu um pino de cocaína, e este tinha ido pegar no muro, quando a equipe policial chegou. Indagado o réu confirmou que a única porção seria para o consumo próprio, negando a propriedade das demais. Por fim, informaram que o local é conhecido pelo tráfico de drogas, e o réu já havia sido abordado em outras oportunidades.

A pessoa de Fagner, ouvida apenas na Delegacia (fls. 10), confirmou a realização da mercancia por parte do réu.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

“Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas” (Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça – art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) - Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente – (...). (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Preliminar – Nulidade da sentença – Ausência de enfrentamento das alegações defensivas e falsidade dos depoimentos judiciais dos policiais militares – Inocorrência – Decisão motivada – Desnecessidade de menção pormenorizada sobre cada uma dos argumentos apresentados – Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para macular a prova colhida – Policiais que não teriam qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados – (...) – Sentença mantida – Recurso não provido (Apelação nº 1501078-10.2017.8.26.0567, da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: SALLES ABREU, Data: 011 de agosto de 2018)

APELAÇÃO – tráfico de drogas qualificado. Apelante que nega o delito. Testemunha de defesa sem credibilidade por contradições e inconsistência fática de sua fala, inclusive com determinação de processo para averiguar o falso testemunho. Testemunhas de acusação coesas quanto ao essencial. Pequeno desvio é derivado da condição de abordagem. Policial é testemunha como qualquer outra pessoa e impugnação a ele deve ser específica, determinada e não genérica pela origem. (...). (TJSP; Apelação Criminal 1500462-48.2018.8.26.0228; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/04/2020;

Data de Registro: 20/04/2020)

Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. 63 (b) - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato. RJDTACRIM VOLUME 6 PÁG.78 ABRIL/JUNHO/90 RELATOR:-JOSÉ HABICE.

Inclusive, julgando Apelação Criminal oriunda deste juízo, assim decidiu a 14ª Câmara do 7º Grupo da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Ressalte-se que, eventuais discrepâncias entre os depoimentos não geram insegurança acerca dos fatos, pois oriundas das imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada, sendo, sim, importante, verificar se, embora divergentes em detalhes mínimos, concordam os testemunhos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias mais decisivas dos fatos" (Apelação Criminal nº 00976517.3/3-0000-000, Rel. DES. FERNANDO MATALLO, 24.05.2007).

Não procedem as alegações da defesa quanto à divergência/imprestabilidade dos depoimentos dos policiais. O depoimento dessas testemunhas tem o mesmo valor que o de qualquer outra, ainda mais quando a mera alegação de sua imprestabilidade vem desacompanhada do menor indício de prova, como no caso dos autos. O entendimento jurisprudencial não é diverso:

Tráfico de entorpecentes - Agente surpreendido trazendo consigo, para fins de tráfico, 21,5 gramas de cocaína, em pó - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. Tráfico de entorpecentes - Dolo de traficar - Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) - Descabimento Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes. (TJSP; Apelação Criminal 0003382-85.2013.8.26.0538; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. (...). 4. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-

os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10).(...). (TJSP; Apelação Criminal 3004956-73.2013.8.26.0318; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/11/2017; Data de Registro: 17/11/2017)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

PROVA - Depoimento de Policiais - Valor:70(a) - Os testemunhos de Policiais possuem validade jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis, inexistindo qualquer vedação legal, sendo certo que, a simples condição de Policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. (Apelação nº 1.179.625/0, Julgado em 22/02/2.000, 14ª Câmara, Relator: Oldemar Azevedo, RJTACRIM 47/274)

A quantidade e forma de acondicionamento do tóxico apreendido evidencia a destinação de tráfico.

Ainda que se considere pequena a quantidade que o réu portava, já ficou patente que os "patrões" do tráfico costumam utilizar-se de pequenos traficantes para a venda. Confira-se à respeito, a matéria do Jornal "O Liberal" de Americana, no dia 21 de junho de 2009:

MICROTRAFICANTES VIRAM O PRINCIPAL FOCO

DA POLÍCIA - Os microtraficantes, como são chamadas pela polícia as pessoas que vendem pequenas quantidades de drogas, são o novo foco dos investigadores da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes). "Esse tipo de traficante é como erva daninha. Quanto mais se prende, mais surge. Por isso temos de combatê-los. Queremos chegar no 'patrão' que está no topo e na base da pirâmide do tráfico", disse o delegado Marco Antonio Pozzetti, titular da DISE. Na semana passada, cinco microtraficantes foram presos. Esta forma de comércio foi criada pelos 'patrões' do tráfico para não sofrerem grandes baixas quando a polícia age. Cada micro fica no ponto de venda, conhecido como 'biqueira', com no máximo 20 unidades de entorpecentes (pedrinhas de crack, papелotes de cocaína e pequenos embrulhos de maconha). Eles são abastecidos pelos 'gatos' como os 'patrões' identificam os distribuidores.

"Os investigadores estão saindo às ruas à procura dos microtraficantes. Na quinta-feira, por exemplo, prendemos um que vendia drogas sentado em um sofá na calçada de sua casa, no Jardim Guanabara. Com ele nós encontramos seis pedrinhas de crack, dois pedacinhos de maconha e mais R\$ 30,00. É o exemplo do microtraficante. Ele

estava com uma quantidade reduzida". Disse o delegado da DISE. "O surgimento dos microtraficantes é uma forma criada pelos 'patrões do tráfico para evitar grandes tombos. Prendemos muitas pessoas e a quantidade de entorpecente apreendida é pequena. Assim, a 'biqueira' não sofre prejuízo", contou o delegado.

Uso próprio

As pessoas que são presas também tentam se beneficiar do artifício da pequena quantidade. Eles procuram provar, na Justiça, que o entorpecente se para uso. Assim, tentam 'quebrar' a prisão de tráfico para uso de entorpecente. "A maioria alega que estava com aqueles papелotes ou pedrinhas par consumo próprio", afirmou um dos investigadores da DISE. Pozeti instruiu os policiais a agirem nas duas pontas da pirâmide do tráfico. "Os micros estão na base e fazendo prisões. Nós conseguimos enfraquecer e até chegar aos donos do comércio", comentou. Os policiais aproveitam as prisões para fazer um mapeamento do esquema do tráfico em Americana. "Nós já sabemos, por exemplo, quem são os responsáveis pelas principais biqueiras. São informações que surgem com as prisões desses microtraficantes", disse o policial. O perfil do vendedor de pequenas quantidades de droga é diversificado, conforme avaliam os policiais da DISE. São adolescentes, jovens e até crianças. Um numero cada vez maior de mulheres tem atuado nas 'biqueirinhas' como costuma chamar o delegado. (...)Em americana, as prisões aconteceram no Jardim Guanabara, Vila Bela, Parque da Liberdade, São Roque, São Jerônimo e na Praia Azul. (...) "O Jardim Guanabara, em Americana, por exemplo, aparece como uma das áreas de grande concentração de pequenos pontos de venda de drogas e vamos intensificar nosso trabalho" afirmou Pozeti.

Cumprе destacar que o local onde o réu foi preso é conhecido como intenso ponto de tráfico de drogas.

O réu nem sequer se dignou em comparecer em Juízo para dar sua versão dos fatos.

Desta forma, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, os objetos e/ou o valor em dinheiro de origem não elucidada permitem a segura conclusão de que o entorpecente apreendido era destinado ao tráfico, razão pela qual é impossível, ainda, a desclassificação para o consumo pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/06). Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: Tráfico ilícito de drogas. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Depoimentos dos policiais civis coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório. Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Incabível. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos narcóticos, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de drogas - A condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 - Redução da pena conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06. Inadequada. A quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos representam perigo maior, atingindo incontáveis usuários, além de apresentarem alto risco à saúde pública com a colocação de tamanha quantidade de entorpecentes na rua - Ademais, as circunstâncias do caso concreto revelam a dedicação habitual do apelante à prática do crime de tráfico ilícito de drogas, não se tratando de mero traficante eventual, que, por descuido, envolveu-se com a traficância momentaneamente - (...) - Pena e regime mantidos Recurso desprovido. (Apelação Criminal nº 0002456-25.2017.8.26.0616, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Presença de indícios tipificadores do delito - Apreensão de grande quantidade de entorpecente - Excessivo poder de compra que não se adequa à condição simples do réu - Aplicação dos artigos 12 e 37 da lei 6368/76 - Recurso não provido. (Relator:

Gentil Leite - Apelação Criminal n. 161.748-3 - Campinas - 01.09.94)

TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Ré surpreendida na posse expressiva quantidade de maconha e uma porção de cocaína - Quantidade e natureza da droga que evidencia o objetivo de mercancia - Recurso não provido. (Relator: Segurado Braz - Apelação Criminal n. 161.094-3 - São José do Rio Preto - 16.05.94)

Pelas provas colhidas nos autos, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar as penas.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, e do art. 42, da Lei 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, é impossível a consideração de qualquer circunstância atenuante, tendo em vista que a pena base foi fixada no mínimo. A questão foi abordada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que lança uma pá de cal sobre a matéria: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Tendo em vista que o réu é primário, não ostenta antecedentes, e não ficou comprovado que se dedique às atividades criminosas e/ou que integre organização criminosa, nos termos do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, diminuo a pena de 2/3 (dois terços), totalizando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Tema 1139, do STJ: É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06. (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR)

Na ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime prisional deverá ser o aberto, nos termos do art. 33, §2º, letra "c" do CP.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao providenciar o cancelamento de sua Súmula nº 512, assentou que o tráfico de entorpecente, em sua forma privilegiada, não tem natureza hedionda.

Nessa linha, consta o julgamento do HC 118.533 do Supremo Tribunal Federal, o qual decidiu pelo afastamento da hediondez do delito de tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO E POR TRÁFICO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA AFASTADA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 23/6/2016, o HC 118.533/MS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, passou a adotar o entendimento de que "o crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda". Posteriormente, a Quinta e a Sexta Turmas do STJ, revendo posição anteriormente adotada, passaram a acompanhar o julgado do STF. Desse modo, a execução penal deve tratar o crime praticado pelo paciente como crime comum, e não como crime de natureza hedionda, para fins de cálculo de possíveis benefícios. Precedentes. 2. Está consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento no "sentido de afastar a reincidência específica em relação ao tráfico privilegiado e o tráfico previsto no caput do art. 33 da Lei de Drogas" (HC n. 471.013/SP, relator

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 16/10/2018). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 547.502/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Ainda, a Resolução nº 5 do Senado, suspendeu a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, inserida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, consagrando o princípio constitucional da individualização da pena. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº.11.343/06. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO APLICADA. PEQUENA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PRIMARIEDADE E MONTANTE DA PENA QUE ENSEJAM O REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. - O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/07/2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. - Ademais, quanto à hediondez do crime de tráfico privilegiado, deve-se acompanhar a decisão do plenário do STF, no exame do HC n. 118.533/MS, julgado em 23/06/2016, de Rel. da Ministra Cármen Lúcia, na qual se assentou que o crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda. - Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF. - Ora, tendo em vista o montante de pena aplicada, no caso, e considerando que as circunstâncias fáticas concretas não desbordam do ordinário do tipo - apreensão de apenas 1 porção de cocaína, pesando 2 g, e 7 porções de crack pesando 3 g (fl. 27) - cabível o regime inicialmente aberto de cumprimento da pena, conforme art. 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal, c/c art. 42, da Lei n. 11.343/2006. - Do mesmo modo, no que tange à possibilidade de substituição da pena, o Supremo Tribunal Federal, em 1º/09/2010, no julgamento do HC n. 97.256/RS, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do § 4º, do art. 33, e do art. 44, ambos da Lei de Drogas, na parte relativa à proibição da conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos aos condenados por tráfico de entorpecentes. - No caso, estabelecida a pena-base no mínimo legal e considerando a primariedade do paciente e a quantidade mínima das drogas apreendidas, também faz jus o acusado à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do CP. - Habeas corpus não conhecido. - Ordem concedida, de ofício, para readequar o regime prisional inicial do paciente para a modalidade aberta e substituir a pena corporal por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juiz singular. (HC 459.796/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 08/04/2019)

Desse modo, cabe ao Julgador verificar a possibilidade de aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 e seguintes do Código Penal.

O réu poderá apelar em liberdade, por estarem ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu GUSTAVO APARECIDO DA ROCHA à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado no piso, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006.

Nos termos dos artigos 43 e seguintes, do Código Penal, em especial os incisos I e IV, do art. 43, converto a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, na forma de prestação de serviços à comunidade, por igual período ao da pena privativa de liberdade, a ser definida pelo Juízo das Execuções, e em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade filantrópica do Município.

Ainda, nos termos do que dispõe o artigo 63 da Lei 11.343/2006 determino a perda dos bens e valores apreendidos, em favor da União, devendo se proceder consoante os parágrafos do mencionado artigo após o trânsito em julgado da presente sentença.

Por fim, considerando ser o réu assistido pela defensoria pública, presumindo-se a insuficiência de recursos, isento-o das custas.
P.I.C.

Americana, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA